

Tokenisation immobilière :

Présentation du modèle de foncière immobilière financée par offre au public d'obligations tokénisées

Par
Florian Freyssenet, fondateur TokenLand
Stéphane Daniel, associé D&A partners

Introduction

Au cours de l'année 2022, l'une des thématiques majeures au sein du vaste écosystème web3 a été la **« tokenisation » immobilière**, avec de multiples projets cherchant à réinventer la manière d'investir dans l'immobilier au moyen de la **technologie blockchain**.

Le pionnier du secteur, **RealT**, un projet fondé en 2019 par des canadiens aux Etats-Unis, plus précisément au sein de l'Etat du Delaware, connu pour la souplesse de son droit des sociétés, a connu un très grand succès.

Aujourd'hui, RealT c'est plus de **250 biens « tokenisés »** pour un total d'actifs sous gestion d'environ 60 millions de dollars. L'entreprise compte plusieurs milliers d'investisseurs uniques, avec une grande partie de francophones. Chaque semaine, la startup propose à des investisseurs particuliers d'acheter des jetons représentant des actions (shares) de sociétés détenant des biens immobiliers à Detroit, Chicago ou Cleveland. Ces jetons peuvent ensuite être utilisés comme garantie pour emprunter sur le **RealT Market Maker** (RMM).

L'essor de ce secteur est aussi porté par une vague de fond consistant à **amener des actifs du monde réel sur la blockchain** (Real World Assets ou Off-Chain Assets), qu'il s'agisse d'actions, d'immobilier ou encore de métaux précieux, et qui semble être l'un des grands narratifs de cette année 2023.

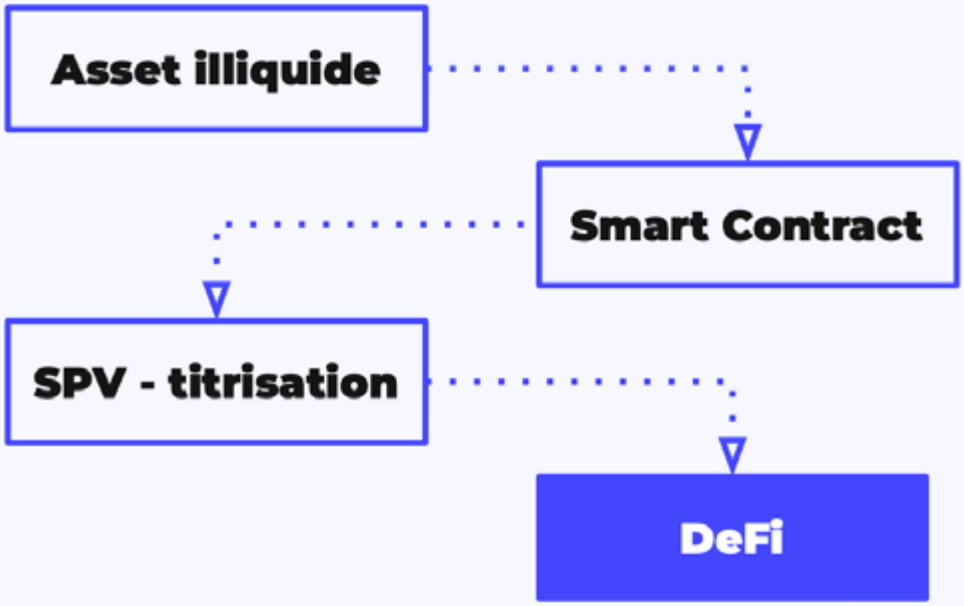
Dans ce contexte, nous proposons dans cet article de faire un point rapide sur **les différentes méthodes de « tokenisation »** immobilière avant de développer le modèle de foncière immobilière privée financée sans intermédiaire par offre au public d'obligations tokenisées.

Au cas présent, nous nous concentrerons essentiellement sur les **aspects relatifs au marché primaire**. Nous nous réservons la possibilité de traiter spécifiquement du marché secondaire dans une seconde publication.

1- Tour d’horizon des différentes méthodes de tokenisation immobilière

Définition de la « tokenisation »

Avant de poursuivre, il convient de définir ce que l’on entend généralement par la notion de « **tokenisation** » de l’immobilier, qui est pour l’heure totalement inconnue du droit français. La « **tokenisation** » consiste tout simplement à **représenter la propriété d’un actif par l’émission d’un jeton (token) enregistré dans une blockchain.**



Or, le droit français ne reconnaît aujourd’hui pas formellement d’effet juridique à l’enregistrement de la propriété d’un actif immobilier dans une blockchain. Ainsi, il est nécessaire de **recourir à des structures alternatives** pour reproduire l’effet économique d’un investissement direct ou indirect dans l’immobilier.

Trois options de tokenisation immobilière

A notre connaissance, il existe **trois principales méthodes** pour proposer une exposition économique sur de l'immobilier au moyen de la technologie blockchain :

- **tokeniser les titres financiers** (actions ou obligations) émis par une société détenant un bien immobilier : à notre sens, cette approche est **la plus viable** et pérenne quand on la compare aux deux autres figurant ci-dessous, et c'est donc uniquement **celle que nous développerons** dans le cadre du présent article.

- **tokeniser les revenus issus d'un bien immobilie**r (fructus) : bien qu'une approche au cas par cas doive être adoptée, depuis la communication de l'Autorité des marchés financiers (« AMF ») du 23 décembre 2022, il semble être clair qu'un jeton auquel serait attachés des revenus issus d'un bien immobilier (par exemple un « royalty token ») devrait **recevoir la qualification de titre de créance** innomé visé à l'article L. 228-36-A du Code de commerce, et devrait être soumis à toutes les règles décrites dans le présent article.

- **tokeniser les services afférents à un bien immobilier** (usus) : bien que séduisante de prime abord, le recours à un jeton de service (utility token) au sens de l'article L. 54-10-1 II du Code monétaire et financier (« CMF »), qui confère un droit d'utilisation du bien immobilier (visite, droit de séjour, etc.), présente un **traitement fiscal qui semble trop défavorable** pour être une option intéressante (taxation en chiffre d'affaires et TVA).

Par ailleurs, il faut préciser que tout schéma qui tenterait de **« déguiser » un security token en utility token**, surtout depuis la dernière communication précitée de l'AMF, **ne saurait prospérer**, car l'AMF privilégie la substance sur la forme du jeton.

Etat du marché français en matière de tokenisation immobilière

L'écosystème français de l'immobilier tokenisé est particulièrement actifs et caractérisé par de **nombreuses tentatives d'innovation** comme en atteste la diversité des projets mentionnés ci-dessous.

Nom	Structure	Blockchain	Localisation
Utility token - Opérationnel			
Wincity	Assets in-game	Ethereum	
Atoa	Fiducie	Polygon	
KonkreteDAO	USDC lending	Ethereum	
Security token - Opérationnel			
RealT	Actions	Ethereum/Gnosis	
Lofty	Actions	Algorand	
Equito	Obligations	Polygon	
Security token - En cours de création			
Blok	Obligations	Elrond	
OpCap	Obligations	Polygon	
Ouibild	Actions	Polygon	
Kryptostone	Actions	Elrond	
Pecule	Actions	Ethereum/Polygon	
Fraktion	Obligations	Polygon	
Algae	Obligations	Ethereum	

Aujourd'hui, il semble ainsi qu'une majorité de projets de tokenisation immobilière français ait opté pour une **structuration sous forme de security token**, et que ceux qui avaient choisi le modèle de « royalty token » soient en train de se restructurer depuis la communication de l'AMF.

Intérêt de la tokenisation

Les **possibilités ouvertes** par le fait de représenter tout ou partie d'un actif immobilier sous la forme d'un jeton sont importantes en raison de sa **composabilité** :

- **modularité** : le jeton peut être **combiné** avec un autre produit / protocole pour créer un autre service. Par exemple, la possibilité d'aller déposer son jeton en collatéral (nantissement) sur un protocole de prêt et emprunt (lending) pour **emprunter des crypto-actifs** ;

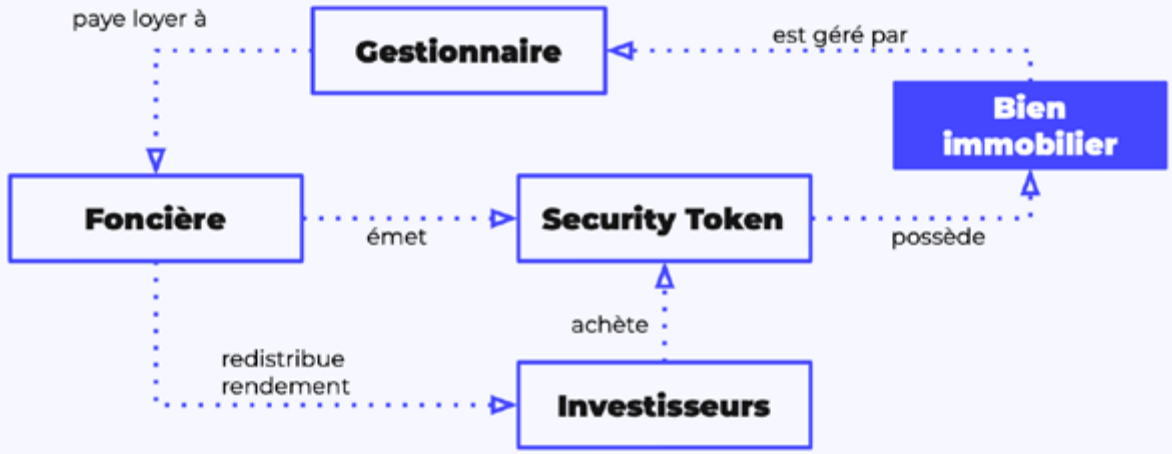
- **accessibilité** : le jeton peut-être **accessible**. Par exemple, la possibilité d'aller échanger son jeton en dehors de l'écosystème de l'émetteur sur une plateforme d'échange décentralisée (decentralized exchange) dans un **environnement non permissionné** (voir par exemple les solutions proposées par Backed.fi, Ondo Finance ou Swarm).

3- Possibilité d'émettre des security tokens en droit français

Dans cette configuration, l'idée est de créer une **société foncière** qui émet par **voie d'offre au public et sans intermédiaire des titres financiers** sous forme de jetons (« security tokens ») pour financer des acquisitions de biens immobiliers.

Son objet peut être soit de faire de la **gestion locative**, dans ce cas, elle assure la gestion et perçoit les loyers, ou bien de la **promotion immobilière**, elle alors assure les travaux de rénovation ou les constructions et revend à terme pour réaliser une plus-value sous réserve des autorisations réglementaires d'activités immobilières.

Dans les deux cas, les revenus issus de ces opérations sont **distribués et partagés avec les investisseurs** qui ont procédé à l'acquisition des security tokens émis par la foncière.



L'article L. 211-3 du CMF prévoit expressément que les titres financiers de sociétés par actions peuvent être inscrits dans un **dispositif d'enregistrement électronique** partagé (« blockchain ») tant qu'ils demeurent non cotés.

Les titres financiers sont définis à l'article **L. 211-1 II du CMF**. Il s'agit des titres de capital, comme des actions, des titres de créances, comme par des obligations, ou des parts ou actions d'organismes de placement collectif, c'est-à-dire de **fonds d'investissement**.

Si l'on met donc de côté la catégorie des fonds d'investissement immobiliers, il est donc possible pour une société par actions d'émettre des actions ou des obligations non cotées sous la forme de **security tokens pour financer des opérations immobilières**.

A cet égard, il est intéressant de noter que le droit français n'impose aucunement de standard technologique pour la représentation du security token. Il est donc possible de **recourir à un jeton fongible ou à un jeton non fongible** (non-fungible token ou NFT).

4- Possibilité d'émettre des security tokens en droit français

Dans l'esprit d'un investisseur en immobilier, il semble toujours préférable d'avoir un lien juridique direct et personnel sur le bien immobilier et idéalement d'être co-propriétaire du bien immobilier.

Dans ce contexte, la structuration d'un projet d'investissement immobilier sous **la forme d'une émission d'actions** semble plus appropriée. Le fait d'être un **« associé »** dans un société est souvent mieux compris et plus facilement accepté que celui d'être un « créancier » de la société.

Pour autant, le choix crucial pour le fondateur d'un projet de tokenisation immobilière ne doit pas s'arrêter à la perspective du marché, mais plutôt au **régime juridique et fiscal qui distingue une action et une obligation**.
Ce choix dépend des objectifs des fondateurs de la foncière et doit être murement réfléchi.

A notre sens, pour ce type de projet, **l'obligation est un meilleur instrument que l'action**, car il est beaucoup **plus souple et moins fiscalisé**, mais le choix est à déterminer par chaque entrepreneur au cas par cas selon les objectifs recherchés.

En revanche, il est important de noter qu'un porteur d'obligation n'est **pas « co-propriétaire »** de l'actif immobilier, il est simplement **créancier**, mais cela ne nous semble pas limitant car **il est possible de créer un lien avec le bien immobilier** par la mise en place de sûretés pour garantir le remboursement de la créance.

Enfin, il est également possible de créer des **titres financiers hybrides**, comme par exemple des obligations convertibles en actions ou des obligations remboursables en actions. Ce type d'instrument peut se révéler intéressant notamment pour permettre aux obligataires de **participer à terme à la plus-value** en cas de revente du bien immobilier.

Nous proposons ci-dessous une comparaison simplifiée des **deux instruments** :

	Actions	Obligations
Nature	Titre de capital : -le porteur est associé de la foncière et donc co-propriétaire du bien immobilier -financement diltif/risque de perte de contrôle -pas d'obligation de verser une rémunération aux associés	Titre de créance : -le porteur est simplement créancier de la foncière -financement non dilutif / aucun risque de perte de contrôle -obligation de rembourser le nominal et de payer les intérêts
Processus d'émission	Augmentation de capital : -décision en assemblée générale extraordinaire -procédure du Code de commerce très rigide, notamment soft cap de 75% -obligation d'avoir recours à un établissement de crédit -souscription en cryptos correspond à un apport en nature et nécessite un commissaire aux apports	Emission obligataire : -décision des organes de gestion -procédure d'émission très souple, pas de soft cap -pas d'obligation d'avoir recours à un établissement de crédit -obligation de nommer un représentant de la masse des obligataires -paiement en cryptos correspond à un paiement en nature sans procédure particulière
Rémunération	Dividendes : -versement annuellement lors de l'approbation des comptes -versement d'acompte possible, mais nécessite bilan intercalaire et commissaire aux comptes -versement possible en numéraire ou en cryptos, mais obligation de proposer une option entre les deux	Intérêts : -taux librement déterminé -périodicité de versement librement déterminée -versement possible en numéraire ou en cryptos, avec possibilité d'imposer un mode de versement en cryptos
Sûreté	Pas de sûreté	Possibilité d'assortir l'émission obligataire de sûreté : hypothèque, nantissement, fiducie
Fiscalité	- Droit d'enregistrement 5% car société à prépondérance immobilière - Intégration dans l'assiette de l'IFI - Dividende et plus-value soumise à la flat tax et versés bruts par l'émetteur	- Droit d'enregistrement 0,1% - Pas d'intégration dans l'assiette de l'IFI - Intérêts soumis à la flat tax et versés nets par l'émetteur
Sort en cas de faillite / liquidation	Rang : paiement après tous les autres créanciers	Rang : paiement après les créanciers munis de sûreté mais avant les associés

5- Régime d'émission : offre au public / placement privé ou *crowdfunding*

La foncière peut se financer directement, c'est-à-dire sans aucun intermédiaire, en émettant le security token par voie d'offre au public ou de placement privé.

En principe, toute offre au public de titres financiers doit faire l'objet de la **publication préalable d'un prospectus** visé par l'AMF conformément au règlement (UE) 2017/1129 du 14 juin 2017 (le « Règlement Prospectus 3 »).

Par exception, le Règlement Prospectus 3 prévoit des cas de dispense de prospectus pertinents pour ce type d'opération.

En premier lieu, il est possible d'effectuer une offre au public dont le montant total est inférieur à 8 millions d'euros sur une période de 12 mois glissants. Dans ce cas, l'émetteur doit déposer un **document d'information synthétique** (« DIS ») auprès de l'AMF et doit impérativement être un **société anonyme** (SA) ou une **société en commandite par actions** (SCA).

En second lieu, il est possible d'effectuer **une offre par voie de placement privé** notamment auprès (i) d'un cercle restreint d'investisseurs de maximum 150 personnes, (ii) d'investisseurs qualifiés ou (iii) pour un montant d'investissement supérieur à 100.000 euros par investisseur.

Alternativement, la foncière peut **se financer indirectement**, en ayant recours à un intermédiaire habilité à faire du crowdfunding et disposant d'un agrément de prestataire de **services de financement participatif** (« PSFP ») (Règlement (UE) 2020/1503 dit « PSFP » du 7 octobre 2020). Dans ce cas, l'offre ne doit pas dépasser un montant total de 5 millions d'euros sur une période de 12 mois glissants.

A cet égard, il est très important de noter que la foncière ne peut être elle-même PSFP, car les règles relatives aux conflits d'intérêts applicables à un PSFP prévoient qu' (i) un PSFP ne peut pas détenir une participation dans une offre de financement participatif qu'il héberge sur sa plateforme et (ii) un actionnaire détenteur de 20 % ou plus du capital social ou des droits de vote du PSFP, un dirigeant ou un salarié ne peut être porteur de projet sur la plateforme (article 12 du Règlement PSFP).:

6- Quel marché secondaire pour un security token ?

Les titres financiers enregistrés dans une blockchain sous la forme de jetons, autrement dit les security tokens, **ne peuvent pas être négociés sur une plateforme de négociation** au sens de l'article L. 420-1 du CMF et ne peuvent donc **pas être côtés** (hors régime pilote issu du Règlement UE 2022/858 du 30 mai 2022).

La seule possibilité offerte par le cadre juridique actuel est d'envisager un **marché secondaire** sous forme de tableaux d'affichage utilisé pour assurer la publicité des intérêts acheteurs et vendeurs sans apparier les ordres ni conclure les transactions (voir position AMF DOC-2020-02).

En raison de ces restrictions, une perspective intéressante pour le modèle de foncière présenté serait de prévoir **une clause de liquidité** permettant aux porteurs des obligations souhaitant sortir de leur position de la revendre à l'émetteur qui pourra ensuite la remettre en circulation à un nouvel acquéreur.

7- Conclusion : une invitation du secteur à explorer plus avant le modèle obligataire

Le recours à la **technologie blockchain** pour développer des solutions d'investissement dans l'immobilier est particulièrement **efficace pour démocratiser l'accès à l'immobilier au plus grand nombre**, notamment via des security token offerings, et rendre le processus d'investissement plus **transparent, efficace et interopérable.**

Afin de profiter pleinement de cette nouvelle technologie, il nous semble qu'à ce jour, **le modèle de foncière privée qui se finance sans aucun intermédiaire** en émettant des obligations représentées par des jetons inscrits dans la blockchain est très intéressant. Le recours aux obligations tokenisées présente les avantages de simplicité, de liberté et de rapidité d'exécution.

Cette solution qui reste à explorer par les acteurs du marché ouvre selon nous **des possibilités prometteuses** :
intérêts variables liés au sous-jacent, remboursement ou conversion en actions, garantie des créanciers par des sûretés sur le bien immobilier, clause de liquidité, marché secondaire sous forme de tableau d'affichage, disponibilité dans un environnement décentralisé, etc.

Nous espérons que le partage de cette étude permettra d'éclairer les personnes qui s'intéressent à la tokenisation immobilière et d'inciter les entrepreneurs à explorer le modèle présenté afin de faire émerger un cadre technologique novateur et juridiquement sécurisé pour investir via la blockchain.

Quelques mots sur les auteurs

Florian Freyssenet

Florian Freyssenet est le fondateur de TokenLand, une société qui accompagne les entreprises et les entrepreneurs dans le développement stratégique et technique (on-chain et off-chain) de leurs projets de tokenisation immobilière. En parallèle, il a conseillé plusieurs acteurs majeurs de l'immobilier, de l'investissement et de la finance dans l'audit, la stratégie et la formation des équipes en immobilier 3.0 (tokenisation, fractionnement, crowdfunding, neo-scpi).

Côté média, Florian est l'auteur du rapport "Immo 3.0 : de la pierre papier à la pierre crypto" et de la newsletter tokenland qui fait référence en France sur les sujets d'immobilier et web3. Il a lancé le club "Immobilier 3.0" qui réunit les acteurs de l'immobilier fractionné en France.

Depuis 2017, il a cofondé l'association Real Estech (devenu un think tank immobilier de premier rang), dirigé le S'lab (incubateur Proptech de Paris La Défense) et cofondé TheDiggers, la plus grosse communauté francophone sur les NFT et la DeFi.

Florian intervient régulièrement en tant que conférencier sur les sujets d'immobilier fractionné, de la tokenisation des actifs ou du metaverse, au sein de grands groupes ou lors de salons et conférences.

Stéphane Daniel

Stéphane Daniel est avocat au barreau de Paris et co-fondateur du cabinet d&a partners, l'un des rares cabinet d'avocats français full service entièrement dédié aux projets tech et blockchain (https://dnapartners.fr), qui a récemment été classé « Band 1 – Excellent » par Décideurs Magazine et a remporté le « Trophée d'Or » 2023 du Sommet du Droit organisé par Leaders League dans la catégorie « cabinet entrepreneurial de moins de 5 ans ».

Stéphane conseille de nombreuses entreprises à forte dimension technologique dans le cadre de leur structuration, levées de fonds ainsi que leurs opérations de fusion et acquisition. Depuis 2017, il est intervenu sur des dossiers emblématiques tels que la structuration en droit français de l'une des premières opérations de tokenisation immobilière, d'ETF sur cryptoactifs et de fonds d'investissement en cryptoactifs de type « Autre FIA ».

Il a développé une expertise de premier plan dans le cadre de la structuration de projets stratégiques et complexes, en particulier dans des environnements hautement réglementés. Il est par ailleurs à l'origine de la structuration juridique en droit français des premières organisations autonomes décentralisées (DAOs), en particulier dans le domaine de la finance décentralisée (DeFi).

Stéphane intervient régulièrement en tant que conférencier sur les sujets de DAO et DeFi au sein de grands groupes et universités françaises (Université Paris II Panthéon-Assas, Université Catholique de Lille).